

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選びなさい。

1. 甲が、Aを脅迫する意図でA宅に宛てて「お前の家に火をつけてやる。」と記載した手紙を郵送したところ、手紙が誤ってA宅の隣のB宅に配達され、Bがこの手紙を読んで畏怖した。甲には、Bに対する脅迫罪が成立する。
2. 甲が、乙に対し、Aの弱みに付け込んでAから現金を喝取するように唆したところ、乙は、その旨決意し、深夜、公園にいるBをAと誤認して、現金を喝取しようとしてBを脅迫したが、人違いのため現金を喝取できず、その直後、Aを上記公園に呼び出し、Aから現金を喝取した。甲には、Aに対する恐喝既遂罪の教唆犯とBに対する恐喝未遂罪の教唆犯が成立する。
3. 甲は、12歳のAを16歳と誤信し、Aに対しわいせつな行為をした（ただし、暴行・脅迫等176条1項、2項に掲げる行為又は事由はないものとする）。甲には、不同意わいせつ罪が成立する。(改)
4. 甲が、乙に対し、Aに暴行を加えるように唆したところ、乙は、その旨決意し、Aに暴行を加えたが、暴行を加えているうちに傷害の故意を生じ、その後の暴行による傷害が致命傷となってAは死亡した。甲には、傷害致死罪の教唆犯が成立する。
5. 甲は、Aが甲に射殺されることに同意したため、Aに対し、殺意をもってけん銃を発射したが、銃弾は、Aに当たらずにAの頭部をかすめ、Aの背後にいて甲がその存在を認識しておらず、甲に射殺されることに同意していなかったBに命中して同人を死亡させた。甲には、Aに対する同意殺人未遂罪とBに対する殺人既遂罪が成立する。

No.43

H22-6

錯 誤

正 解

3、5（順不同）

正答率

59%

本問は、犯罪事実につき行為者（肢1、3、5）又は教唆者（肢2、4）が行為当時又は教唆当時認識した犯罪事実と、現実には発生した結果とが一致しない場合（事実の錯誤）に、発生した犯罪につき故意（38条1項本文）を認めることができるかという問題についての判例の立場の理解を問うとともに、各犯罪の構成要件の理解を問うものである。

この点、判例は、「犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実には発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもって足りる」としており（法定的符合説）、行為ときに認識した犯罪事実と現実には発生した結果とが構成要件の評価上符合している限り、発生した犯罪（認識外の客体に結果が発生した場合も含む）に故意を認める数故意犯説を採用している（最判昭53.7.28）。この「法定の範囲内」とは、「犯罪の類型（定型）として規定している範囲内」（最判昭25.7.11）という趣旨であると解されている。

そして、これは教唆犯についても同様に妥当し、教唆当時認識した犯罪事実と現実には発生した結果とが構成要件の評価上符合している限り、発生した犯罪に故意が認められる（大判大9.3.16）。

判例の結論に賛成する学説は、その理由として、故意の本質は構成要件に該当する事実を認識し、その事実を実現する意思にあるから、法定の構成要件で類型化された事実の認識があれば足りるということを挙げている。

他方、錯誤が異なる構成要件に属するときには、重い罪によって処断されず（38条2項）、故意を欠く重い罪は成立しないが構成要件が重なり合う限度で軽い罪が成立する（最判昭54.3.27）。

1 正しい

本記述では、現実には甲が郵送した手紙はB宅に配達されBが畏怖したところ、甲はAに対する脅迫の故意で手紙を郵送したことから、甲にBに対する脅迫罪（222条1項）の故意を認めることができるかが問題となる。この点、脅迫罪の構成要件上の客体は「人」である。そのため、甲が行為当時認識した客体Aと、現実には畏怖させた客体Bの両者は、「人」であるという点で、法定の範囲内において一致する。そうすると、甲にはBに対する脅迫についての故意を認めることができる。よって、甲には、Bに対する脅迫罪が成立する。

2 正しい

本記述では、乙は甲の教唆により、Bに対して恐喝の実行行為としての脅迫を行っているが、甲の教唆内容は「Aに対する恐喝」であった。そこで、このような場合にも甲にBに対する恐喝未遂罪（250条、249条1項）の教唆（61条1項）の故意が認められるかが問題となる。この点、恐喝罪の構成要件上の客体は「人」である。そのため、甲が教唆当時及び乙が行為当時認識した客体Aと、乙が現実には脅迫した客体Bの両者は、「人」であるという点で、法定の範囲内において一致する。そうすると、乙にはBに対する恐喝についての故意を肯定することができ、そして甲にも乙のBに対する恐喝についての教唆の故意を認めることができる。よって、甲には、Bに対する恐喝未遂罪の教唆犯が成立し得る。また、乙はBから喝取できずに終わった直後に、甲の認識通りAから現金を喝取している。そのため、乙のAに対する恐喝は、甲のAに対する恐喝の教唆に基づくものといえる。よって、甲には、Aに対する恐喝既遂罪の教唆犯が成立し得る。

もっとも、甲の教唆行為は1つしかないので、A、B2名に対する2つの教唆犯が成立する

かが問題となる。この点、1つの幫助行為で正犯が2つの犯罪を実現したという事案について、判例は、「幫助罪は正犯の犯行を幫助することによって成立するものであるから、成立すべき幫助罪の個数については、正犯の罪のそれに従って決定される」として、2つの幫助犯の成立を認めた上で、両罪は観念的競合の関係にあるとしている（最決昭57.2.17、百選I107事件）。よって、甲には、Aに対する恐喝既遂罪の教唆犯とBに対する恐喝未遂罪の教唆犯が成立する。

3 誤っている

本記述では、甲は12歳のAに対して176条1項及び2項に該当しない形でわいせつな行為をしており、かかる行為は、Aに対する不同意わいせつ罪（176条3項）の客観的構成要件に該当する。ところが、甲はAを16歳と誤信していたことから、甲に同条3項の不同意わいせつ罪の故意が認められるかが問題となる。この点、故意とは、犯罪事実（客観的構成要件要素に該当する事実）の認識・認容をいい、行為の客体が「16歳未満」であるという事実についての認識を欠く場合には、同条3項についての故意は認められない。そうすると、行為当時Aを16歳と誤信しており、行為の客体が「16歳未満」であるという事実の認識を欠く甲には、12歳のAに対する不同意わいせつ罪についての故意を認めることはできない。よって、甲には、Aに対する不同意わいせつ罪は成立しない。

4 正しい

大判大13.4.29。本記述では、現実には甲の教唆により乙はAに暴行を加えているうちに傷害の故意を生じ死の結果を発生させたところ、甲は暴行の故意で乙に教唆していたことから、甲に結果的加重犯の重い結果が帰責され、傷害致死罪（206条）の教唆犯が成立するかが問題となる。この点、判例は、人を教唆して他人に暴行を加えさせた以上は、その暴行の結果他人の身体を傷害し、よって死に致させた場合には、教唆者は傷害致死の罪責を負うべきことは当然であるとして、結果的加重犯の重い結果を教唆者に帰責させることを認めている（大判大13.4.29）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、結果的加重犯の重い結果に過失を不要とする判例（最判昭26.9.20）の立場からは当然のことであるということを挙げている。よって、甲には、傷害致死罪の教唆犯が成立する。

5 誤っている

本記述では、まず、甲は、Aが甲に射殺されることに同意したため、Aに対し、同意殺人の故意をもってけん銃を発射したところ、銃弾がAに当たらずにAの頭部をかすめるにとどまっている。よって、甲には、Aに対する同意殺人未遂罪（203条、202条後段）が成立する。

次に、現実には甲は射殺されることに同意していなかったBを死亡させているところ、甲は同意殺人の故意でけん銃を発射したことから、甲にBに対する殺人既遂罪（199条）が成立するかが問題となる。この点、殺人罪と同意殺人罪は、基本的構成要件とその減輕構成要件の関係にあるとされる。すなわち、殺人罪と同意殺人罪は、軽い同意殺人罪の限度で重なり合いが認められる（大判明43.4.28参照）。そのため、重い罪である殺人罪に当たる行為をしたとしても、同意殺人の故意しかなかった場合には、殺人罪は成立せず、同意殺人罪が成立する。よって、甲には、Bに対する同意殺人既遂罪は成立するが、殺人既遂罪は成立しない。